

常依靠搜索引擎自身的算法，根据关键词的匹配度降序排列，且根据搜索引擎的算法不同，搜索结果展示的顺序可能也存在不同。经营者通常希望消费者在搜索时能在相对靠前的位置看到与经营者相关的搜索结果，则会向搜索引擎服务商的推广服务中设置一定的关键词，以提升自身网站的搜索结果排序。这是网站推广商业经营中常见的经营行为。网站经营者在设置关键词时，通常将所经营网站的名称、自身企业名称、销售的商品类别及商品名称、提供的服务内容等设置为关键词，以便消费者能快速获得想要的搜索结果。根据本案查明的事实，乙科技公司在某搜索引擎推广中设置了“××A网PPT”作为推广关键词，该关键词中的“××A网”并非乙科技公司经营的网站名称，而是甲科技公司所经营的同类网站的网站名称。乙科技公司设置同业竞争者所经营网站的名称作为某搜索引擎搜索的关键词，明显不具有正当性，违反了商业道德，扰乱了正常的商业竞争秩序。

其次，关键词隐性搜索行为是否损害甲科技公司或消费者的合法权益需结合具体案情逐一判断，这也是涉关键词隐性搜索类案件中个案结论不一的重要原因。搜索结果显示的位置和搜索结果展示方式的不同，会直接影响消费者点击相应搜索结果的判断。一般来说，搜索引擎检索排序是以与关键词的匹配度降序排序。作为理性的消费者，在已经获得了所需要的正确搜索结果后，通常是不满足第一屏的搜索结果才会进行下一步的操作来查看后续与所搜索关键词匹配度更低的搜索结果。搜索位置靠前的搜索结果会使得消费者认为与键入的关键词关联度更大，而搜索位置靠后的搜索结果则容易让消费者认为与键入的关键词关联度更低。而且若搜索结果以明确的“广告”字样或加一定底色、边框的方式与自然搜索结果区分开来的话，更容易让消费者认识到该搜索结果系通过竞价排名的方式展示在搜索结果中。本案中，乙科技公司在某搜索引擎推广中设置甲科技公司享有合法权益的词语“××A网PPT”作为推广关键词，使得网络用户在某搜索引擎搜索“××A网”时，搜索结果第一页的尾部出现了乙科技公司“××B网”的搜索结果。需要注意的是，该搜索结果位于搜索结果展示页面的第十二条，即展示页面的倒数第二

条搜索结果,且该搜索结果中并不含有“××A网”字样并明确标明了“××B网”,点击该搜索结果跳转至“××B网”,跳转后的网站中亦不存在“××A网”字样。而搜索结果靠前位置的多项搜索结果均为与甲科技公司自身相关搜索结果。可见,消费者在某搜索引擎网搜索“××A网”时,展示的搜索结果第一屏显示的大部分均是甲科技公司“××A网”信息,只有当消费者选择下拉或下滑操作继续浏览更多其他的搜索结果时才能看到乙科技公司“××B网”的搜索结果。从消费者的角度来看,消费者在搜索“××A网”关键词时能够直接在第一屏即获得正确的搜索结果并予以展示。且乙科技公司网站搜索结果中明确展示了“××B网”,搜索结果中亦没有“××A网”字样,这种程度的展示一般来说难以影响消费者的利益,亦不会影响消费者选择商品、服务的权利。从作为经营者的甲科技公司来看,消费者在搜索“××A网”时,搜索结果展示的第一屏内容大部分均是甲科技公司“××A网”的信息,已经保证了甲科技公司经营的“××A网”对于消费者的可见性,甲科技公司并不会失去存在交易意愿的消费者。乙科技公司网站的搜索结果位于需要进行下滑操作的网页后部,只有对于与甲科技公司交易意愿不强烈的消费者才会进行下一步操作以寻求更多的搜索结果。可见,乙科技公司设置“××A网PPT”作为某搜索引擎推广关键词的行为不必然导致甲科技公司交易机会的丧失,客观上甲科技公司亦未能证明其实际因此遭受了损害。

结合上述两方面因素的分析可见,本案中虽然乙科技公司在某搜索引擎推广设置甲科技公司享有权益的词语作为关键词的行为违反了正常的商业道德及商业竞争秩序,但未损害甲科技公司或消费者的合法权益。即在适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条认定某一行为是否属于不正当竞争行为时应考虑的两个因素中仅符合第一个因素的情况下,不宜认定该相关关键词隐性搜索行为构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条所规定的不正当竞争行为。

三、关键词隐性搜索行为应有其限度

即便在本案中最终认定涉案关键词隐性搜索行为不构成不正当竞争行为,司法实践中不宜直接对相关行为作正面评价。广告主将他人享有权利或权益的

名称作为关键词的行为，确实不符合正常的商业道德，不应予鼓励。关键词隐性搜索行为在侵权与否的边缘地带，若对此行为予以积极评价会导致同业竞争者竞相设置彼此有关的关键词予以推广，扰乱正常的商业竞争秩序，最终会导致相关行为跨入法律对权利保护的边界，对权利人和消费者造成损害，最终构成侵权。搜索引擎运营商在经营其竞价排名的关键词设置时亦应对广告主尽到提示的义务，对于出现在搜索结果顶部的竞价关键词应进行一定程度的审核，以避免出现损害消费者、关键词权利人相关权利的情况。

编写人：上海市浦东新区人民法院 王琳珑

53

传统食品配方和制作工艺的商业秘密认定及保护

——某甲食品厂诉某乙食品公司、母某丙侵害商业秘密案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

最高人民法院(2022)最高法知民终995号民事判决书

2. 案由：侵害商业秘密纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某甲食品厂

被告(上诉人):某乙食品公司、母某丙

【基本案情】

2013年3月5日，某甲食品厂与某大学生命科学学院签订《技术成果转让协议》。该协议约定，某大学生命科学学院为某甲食品厂水豆豉生产提供纯种发酵技术支撑，指定专人负责培育菌种与生产事宜。2014年1月10日，

某甲食品厂与某大学生命科学学院 W 教授签订《专利许可使用协议》，约定 2014 年 1 月 10 日至 2019 年 9 月 10 日，某甲食品厂通过每年支付 W 教授 100000 元专利使用费方式取得 W 教授提供的专利菌种及其配套豆豉生产技术。2014 年 5 月 30 日，某大学生命科学学院及某甲食品厂合作项目“枯草芽孢杆菌菌株改良及其配套技术研究与应用”获省科技厅颁发《科学技术成果鉴定证书》。枯草芽孢杆菌系用于发酵水豆豉的重要菌种。2014 年 9 月 27 日，某甲食品厂与某大学生命科学学院签订《校企合作协议》，约定双方共建发酵豆制品研发中心，某甲食品厂投入资金，某大学生命科学学院投入技术及科研人员。

2015 年 1 月 1 日，某甲食品厂与母某丙签订《劳动合同书》，合同届满期限为 2017 年 12 月 31 日。约定母某丙从事食品生产工作，其工作期间须遵守相关保密制度，并约定竞业禁止条款。2015 年 12 月 9 日，母某丙被任命为生产车间副主任，负责酱香豆豉车间生产工作。且某甲食品厂水豆豉与酱香豆豉因生产工艺中部分技术相同而共用同一个生产车间。2017 年 7 月，母某丙在劳动合同期限未届满且未办理离职手续情况下离职。2015 年 12 月 8 日，某甲食品厂与案外人肖某签订《肖某豆豉转让协议》，某甲食品厂取得肖某豆豉生产技术及秘方。

另查明，2018 年 9 月 6 日，公安机关委托产品质量检测机构抽样选取市场上销售的包括案涉某甲食品厂、某乙食品公司生产的水豆豉在内的五个品牌水豆豉进行对比检测。检测内容包括，总酸、氨基酸态氮、盐分三项理化指标。《检测报告》显示：三项理化指标项下，某甲食品厂、某乙食品公司的产品差异较小。

指标 品牌	“美 x x” (某甲食品厂产品)	“苗 x x” (某乙食品公司产品)	“老 x x” (案外人产品)	“乡 x x” (案外人产品)	“老 x 1” (案外人产品)
总酸	0.45%	0.44%	1.09%	1.20%	1.0%
氨基酸态氮	0.77%	0.63%	1.11%	0.77%	1.29%
盐分	5.8%	5.6%	6.8%	5.0%	6.2%

2018年10月23日，公安机关委托行业协会对上述五个品牌水豆豉进行品鉴盲评测试。经测试，专家组成员意见基本一致，认为某甲食品厂、某乙食品公司的产品在滋味、风味、口感、色泽及相应工艺上相似。

2019年9月20日，某甲食品厂起诉某乙食品公司及母某丙；2020年1月14日，某乙食品公司厂房发生火灾，因生产车间损毁，故无法对其生产场所、设备等进行现勘。

经合议庭释明及引导，某甲食品厂明确以下技术信息和经营信息属于其商业秘密：第一，生产工艺流程中的N次恒温发酵技术及投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉；N次恒温发酵技术是在水豆豉生产过程中，将已经过一次发酵的水豆豉灌装入瓶，在恒温环境中，让水豆豉在瓶中与微生物再次充分融合进行第N次发酵。该技术主要解决现有只经一次发酵的水豆豉成品上市后，因微生物持续发酵而产生的“顶盖”以及风味酸败的问题。投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉目的亦是防止投料过程中，因生姜与辣椒粉中附带的微生物发酵或细菌繁殖导致水豆豉腐坏，以保持水豆豉风味更加稳定，减少“顶盖”率和霉变率。上述技术系某甲食品厂通过与某大学生命科学学院合作，控制产品参数、原料、配方等，经反复试验后形成的一套生产技术。该技术目前市场上或公知领域现有的水豆豉制作工艺相区别。第二，生产设备；生产水豆豉的设备系在某大学生命科学学院科研人员指导下，改良传统设备以提升效率。第三，供货商资源；供货商与其长期合作。

再查明，某甲食品厂成立于2005年9月9日，经营范围生产发酵型豆制品等；2017年10月17日，母某丙与周某1、翟某投资成立某乙食品公司，经营范围为食品加工等；2019年6月14日，母某丙退股，变更后的股东为周某1、翟某、周某2。

【案件焦点】

1. 某甲食品厂生产工艺及配方、生产设备、供货商资源是否构成商业秘密；
2. 某乙食品公司、母某丙是否实施了侵害某甲食品厂商业秘密的行为；
3. 某甲食品厂诉请赔偿的金额及合理开支是否有事实及法律依据。

【法院裁判要旨】

贵州省贵阳市中级人民法院经审理认为：关于焦点一，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第四款，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第三条、第五条、第七条第一款之规定，商业秘密构成要件为：“不为公众所知悉”“价值性”“采取保密措施”。

关于“不为公众所知悉”，即秘密性，具有两层含义：一是技术信息或经营信息在该领域内是否已被知悉为客观事实，多数人已确实知悉该信息；二是该领域内多数人具有通过正当途径可轻易知悉的可能性。本案中，某甲食品厂主张其生产过程中的N次恒温发酵技术及投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉为其商业秘密。根据其提交的证据，上述信息属于技术信息，系生产过程中，在恒温环境下，通过利用微生物与经一次发酵的水豆豉再次充分融合进行第N次发酵；在投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉，上述两项技术的目的均是阻却微生物持续发酵产生“顶盖”现象并保持水豆豉风味更稳定，减少霉变率。上述技术系某甲食品厂与某大学生命科学学院联合研发，且不同于传统制作工艺，于公开渠道不易获取。此外，某乙食品公司及母某丙未举证证明上述生产技术及配方不具有秘密性，故可确认上述生产技术及配方不为公众所知悉，具有秘密性。

关于“价值性”，即技术信息及经营信息通过现在的或将来的使用，能给权利人带来现实或潜在经济价值。某甲食品厂通过上述生产技术及配方对水豆豉生产工艺及配方加以科学优化，经批量化生产，产品风味良好、稳定，在区域性水豆豉食品市场销量较好，具有商业竞争力，故可确认上述生产技术及配方能给企业带来经济利益和竞争优势，具有价值性。

关于“采取保密措施”，即保密性，技术信息及经营信息的权利人采取实际措施对信息加以具体保密措施。本案中，某甲食品厂与母某丙签订的《劳动合同书》《保密协议》均明确约定员工需要保密的具体内容，并要求遵守竞业禁止协议，故可确认某甲食品厂采取合理保密措施。

综上所述，N次恒温发酵技术及投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉

满足商业秘密构成要件，系商业秘密，应受法律保护。

关于某甲食品厂主张其生产设备及供货商资源属于商业秘密，但某甲食品厂未提交证据证明其生产设备满足商业秘密的构成要件；其提交的关于供货商信息亦不满足商业秘密的构成要件，故对该两项主张不予支持。

关于焦点二，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款、第三款之规定，侵犯商业秘密行为具有隐蔽性，应根据“实质性相同+接触”原则判断是否构成侵权。本案中，水豆豉为发酵型食品，其生产过程中会因发酵温度、时间、微生物菌群、配料比例等客观条件不同而产生不同风味、色泽等。某甲食品厂为证明其产品特殊性，提供的《技术成果转让协议》《专利许可使用协议》《肖某豆豉转让协议》等证据足以证明，在水豆豉生产行业，不同企业产品具有差异性，水豆豉系一种可区分、非标准化食品。

并且，经公安机关委托产品质检机构对包含某甲食品厂、某乙食品公司生产的水豆豉在内的五个品牌水豆豉的总酸、氨基酸态氮、盐分进行理化指标检测。结论为，某甲食品厂、某乙食品公司的产品差异较小，但某甲食品厂产品与案外人产品差异较大。经公安机关委托行业协会组织品鉴专家对上述五个品牌水豆豉在风味、口感、色泽等进行盲评。盲评结果显示，某甲食品厂、某乙食品公司的产品在滋味、风味、口感、色泽及工艺上相似。由此可认定，某甲食品厂、某乙食品公司的产品在理化指标、品鉴风味、口感等均高度近似。

另，母某丙于2015年12月9日被任命为生产车间副主任，负责酱香豆豉车间生产工作。因水豆豉与酱香豆豉共用同一个生产车间，故其有机会接触到水豆豉生产技术及配方。2017年7月，母某丙在劳动合同期限未届满且未办理离职手续情形下离职；同年10月17日，其与另两名自然人投资成立某乙食品公司，该公司同样生产水豆豉等食品。从母某丙离职到某乙食品公司成立，再到其生产的水豆豉上市销售，约两个月时间。虽然水豆豉是一种传统食品，普通人按照一定方法能够制作，但不同主体制作工艺和配方有差异，导致制作出来的水豆豉风味、口感等各不相同。更为重要的是，普通家庭式生产与规模化的工业生产不同。在工业化生产中，公司从成立到研发，再到产品上市销售，

并非短时间内能完成。并且，某乙食品公司称其按照网络搜索的方法生产水豆豉，但该证据不足以证明其使用的制作方法能制作出与某甲食品厂理化指标及滋味、风味、口感均高度相似的水豆豉。其提交的豆豉贵州省地方标准及其《工艺流程说明》均无法证明其生产工艺可与某甲食品厂相区分，未能证明其正当性。

综上，可认定，某乙食品公司使用水豆豉生产技术和配方与某甲食品厂水豆豉生产技术和配方实质性相同，且某乙食品公司股东母某丙有机会接触该商业秘密，某乙食品公司、母某丙实施了侵害某甲食品厂的商业秘密的行为。

关于焦点三，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十七条第一款、第三款、第四款之规定，本案中，某甲食品厂主张1000000元经济损失，但鉴于某甲食品厂并未提供证据证明其因某乙食品公司及母某丙侵犯其商业秘密造成的损失或二者的获利，综合考虑某乙食品公司、母某丙行为性质、经营规模、地域范围、合理维权费用等因素，酌情确定某乙食品公司及母某丙连带赔偿某甲食品厂经济损失及合理开支共计200000元。

贵州省贵阳市中级人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条之规定，判决如下：

一、某乙食品公司及母某丙立即停止侵犯某甲食品厂商业秘密并销毁侵权产品、半成品；

二、某乙食品公司及母某丙于一审判决生效之日起十日内连带赔偿某甲食品厂经济损失及合理开支共计200000元；

三、驳回某甲食品厂其余诉讼请求。

某乙食品公司、母某丙不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院经审理认为：第一，涉案生产工艺及配方不同于传统水豆豉制作的常识性工艺及配方，也不属于该领域普遍知悉的技术信息，并为权利人带来一定的市场优势及实际的经济效益，权利人亦通过制定保密制度及在劳动合同中

约定保密内容等方式采取了保密措施，故涉案生产工艺及配方构成技术秘密。第二，在侵害技术秘密诉讼中，权利人主张的技术秘密为某种产品的制造工艺或制造方法，其提供的证据能够证明侵权产品与使用权利人技术秘密制造的产品属于相同产品，且侵权产品使用权利人技术秘密的可能性较大，同时权利人为证明侵权人使用了其技术秘密已尽到合理努力的，而侵权人不能提供有效证据证明侵权产品未使用权利人技术秘密的，可以认定侵权人使用了权利人的技术秘密。

最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商业秘密因不具备法定权利外观，由权利人持有，故商业秘密案件在权利存在、权利归属、权利内容和保护范围的确定以及侵权构成等方面具有一定难度及特殊性。如何破解审理难题，承办人选择从以下几方面入手：

一、合理运用法官释明权，引导当事人精准划定商业秘密范围

司法实践中，审理侵犯商业秘密纠纷案件必须首先明确商业秘密的范围，即“秘密点”，这是此类案件审理中的重点和难点。由于权利人或其代理人对商业秘密法定要件不熟悉、不了解，存在范围越大保护越多的理解误区以及举证能力较弱等问题，此类案件起诉时，权利人往往会划定“大而全”秘密范围，有的权利人甚至在案件审理之初因担心“泄密”不愿说出其“秘密点”。此时，法官合理运用释明权是审理好商业秘密案件的关键。第一，在技术秘密类案件中，明确“不为公众所知悉”的技术信息是指这类信息的排列组合、构成要素、制备方法等并非为涉及这些信息范围内的人员所了解掌握或容易获取。这就要求法官需要向当事人释明并引导当事人反复筛选、仔细甄别其技术信息或经营信息，并将这些信息与公知技术有效区分，最终精准确定“秘密点”。这一过程往往复杂且争议极大，一般需要经过若干次质证或庭审才能完成。第二，法官不仅应引导被控侵权人进行公知技术抗辩，还需引导其进行相关举证。

本案件审理过程中，权利人最初将整个水豆豉制作工艺作为其商业秘密要求法院予以保护。经三次庭审及法官反复释明，并结合被控侵权人抗辩意见，经反复讨论、筛选、甄别，最终将原先范围很大的秘密点逐渐予以明晰并合理缩减，由整个水豆豉制作工艺缩减为N次恒温发酵技术及投料阶段使用经某种工艺灭菌的生姜与辣椒粉。

二、“不为公众所知悉”的认定规则及“盖然性占优势”举证责任的运用

“不为公众所知悉”，即秘密性，具有两层含义，一是技术信息或经营信息在该领域内是否已被知悉为客观事实，多数人已确实知悉该信息；二是该领域内多数人具有通过正当途径可以轻便知悉该信息的可能性。这是商业秘密的核心构成要件，也是最难证明的要件。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条规定，权利人提交商业秘密“不为公众所知悉”的优势证据或对其主张的商业秘密信息与公有领域信息的区别点作出充分合理的解释或说明的，即可以认定秘密性成立。此时，权利人完成初步举证责任。被控侵权人反驳权利人商业秘密“不为公众所知悉”的，则由其就该反驳主张承担举证责任。换言之，权利人仍应对“不为公众知悉”这一基础性事实负有举证责任，但这种举证到何种程度，是否必须达到“高度盖然性”的标准，答案是否定的。司法实践中，如权利人提交完整技术图纸或参数、实验数据和结果、工艺流程改进方法记录、技术秘密的查新报告、鉴定报告、有专门知识的人出具的意见等，或对商业秘密的形成或来源，与公开渠道可以获得的信息的区别等作出说明，即完成举证义务。此时，被控侵权人主张案涉商业秘密“为公众所知悉”的，应对其对该反驳主张承担举证责任，其举证不能，法官则可运用“盖然性占优势”的证明标准认定权利人主张成立。

本案中，权利人提交《技术成果转让协议》《专利许可使用协议》《科学技术成果鉴定证书》《校企合作协议》《肖某豆豉转让协议》等证据证明其投入人力、物力、财力对水豆豉发酵工艺进行研发、改进，通过控制温度参数、投料配方等反复试验后形成的生产工艺及配方，且区别于市场上或公知领域现有的水豆豉制作方法。通过上述生产技术及配方对水豆豉这一传统食品的生产工艺

